



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/420/2021
מס' בקשה: 6/552/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

אליהו מנשה
באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב גלאי

התובע:
(המשיב)

נגד

כהן אפרת רחל
באמצעות ב"כ: עו"ד שרף נפתלי

הנתבעת:
(המבקשת)

החלטה

לפניי בקשה שהגישה הנתבעת לסילוק התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות, בשל הליך בוררות (להלן – "הבקשה").

הרקע לבקשה

1. עניינה של התביעה בבית המשותף ברחוב אבטליון 32 אלעד, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך ט"ו בסיון תשס"ה (22.6.2005), והידוע כחלקה 3 בגוש 5459 (להלן – "הבית המשותף").
2. הבית המשותף מורכב משלושה מבנים בעלי שלוש קומות כל אחד ו-27 יחידות בסך הכול. לבית המשותף תקנון מוסכם מתאריך ט"ו בסיון תשס"ה (22.6.2005) (להלן – "התקנון המוסכם").
3. על שם התובע, מנשה אליהו (להלן – "התובע") רשומה הערת אזהרה על דירה הידועה כתת חלקה 19, הנמצאת בקומת הקרקע בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/420/2021
מס' בקשה: 6/552/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. הנתבעת, אפרת רחל כהן (להלן – **"הנתבעת"**) היא בעלת הזכויות של דירה הידועה כתת חלקה מספר 25, הנמצאת בקומה השנייה בבית המשותף.

5. בתאריך 14.7.2021 הגיש התובע כתב תביעה (להלן – **"כתב תביעה"**) בבקשה למתן צו עשה המורה להרוס בניה בלתי חוקית שנבנתה על ידי הנתבעת ללא היתר על הרכוש המשותף. נטען כי הנתבעת הרחיבה את דירתה בהיתר שקיבלה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה באלעד, אך לאחר מכן המשיכה ובנתה בגג המשותף ללא היתר בניה וללא הסכמת השכנים.

6. בתאריך י"ב בחשוון תשפ"ב (18.10.2021) הגישה הנתבעת הבקשה שבכותרת, בה נטען כי מכוח סעיף 5(א) לחוק הבוררות תשכ"ח-1968 (להלן – **"חוק הבוררות"**), יש לסלק את התביעה וזאת מאחר שלטענתה מתנהל כבר הליך בוררות בעניין זה. עוד נטען כי התובע אינו הבעלים של המקרקעין אלא בעל הערת אזהרה בלבד ומי שמתגורר בנכס בפועל הוא בנו, מר אילן אליהו (להלן – **"אילן"**).

בהתאם לנטען, אילן ושאר השכנים חתמו בעבר על הסכמתם לבנייה ועל ויתור חלקם בגג המשותף לטובת הנתבעת, אך לאחר מכן נוצר סכסוך שכנים, במסגרתו פנו, אילן ובעלה של הנתבעת, מר משה כהן (להלן – **"משה"**) לבית הדין "חושן משפט" באלעד (להלן – **"הליך הבוררות"**), כדי שיכריע בסכסוך, ואכן במסגרת הליך הבוררות ניתן פסק דין חלקי. לטענת הנתבעת, התובע מנסה לעקוף את התחייבותו ואת פסק הבורר ולשבש את הליך הבוררות.

7. בתאריך ג' בכסלו תשפ"ב (7.11.2021) הגיש התובע תגובה לבקשה לסילוק התביעה על הסף (להלן – **"כתב התגובה"**) הטענה העיקרית בכתב התגובה היא ששטר הבוררות (ראו: נספח 3 לבקשה לסילוק על הסף) נועד לברור מחלוקת הקשורה לנזקים כספיים שנגרמו למתגורר בדירה בעקבות הבניה וכמו כן טענות על ריבוי דיירים ושינוי מקום הדודים, ואילו התביעה לפני המפקח על המקרקעין נולדה בשל עילה אחרת, הבנייה הבלתי חוקית. נטען כי הבניה הבלתי חוקית אינה מעניינה של אילן, אלא עניינה של התובע בעל הזכויות. בנוסף לכך, מכוח סעיף 5(א) לחוק הבוררות יכולה הנתבעת לבקש עיכוב הליכים ולא סילוק על הסף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/420/2021
מס' בקשה: 6/552/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. בתאריך ט' בטבת תשפ"ב (13.12.2021) הוגש כתב ההגנה (להלן – **"כתב הגנה"**) במסגרתו טענה הנתבעת כי בינואר 2021 שלח אילן מכתב התראה שבו הציג את עצמו ואת אשתו כבעלי הזכויות במקרקעין. המכתב נשלח אל משה, בן זוגה של הנתבעת, ובעקבותיו פנו אילן ומשה להליך בוררות, לפיכך יש להתייחס אל אילן כבעל זכויות או כשליח מיופה כוח. במהלך הליך הבוררות טען אילן בשמו ובשם התובע טענות נגד הבנייה של הנתבעת ובעלה וגם לאחר הגשת התביעה שבכותרת, אילן ממשיך להתנהל בהליך הבוררות. לטענת הנתבעת, התובע או אילן או שניהם מנסים לעקוף את התחייבותם ואת פסק הבורר בחוסר תום לב.

9. בתאריך כ"ט בטבת תשפ"ב (2.1.2022) התקיים דיון בעניין הבקשה לסילוק התביעה על הסף, ובמסגרתו נשמעו עדויות הצדדים בקשר לבקשה (להלן – **"הדיון"**). בתום הדיון החלטתי לאפשר לצדדים להגיש את סיכומיהם בכתב.

טענות (המבקשת) הנתבעת בסיכומיה

10. הליך הבוררות דן בזכויות קנייניות ובזכויות נזיקיות, התובע טען בדיעבד כי הבוררות התנהלה רק לגבי נושאים נזיקיים אף על פי שביקש לפצל את סעדיו כדי שיוכל לתבוע בנזיקין.

11. בתאריך כ"ט בטבת תשפ"ב (2.1.2022) התקבל פסק דין מבית הדין (להלן – **"פסק הבוררות"**) ובו פורט כי בהליך הבוררות נדונו גם הליכים קנייניים וכמו כן בפרק "הנימוקים לפסק הדין" נכתב כי התובעים בבוררות התנגדו לכך שהנתבעת בנתה על כל הגג, טענה זו נדחתה. בפסק הבוררות נקבע כי השכנים בחתימתם ויתרו על הגג והסכימו להצמדת השטח לדירתה של הנתבעת (ראו: נספח 3 לסיכומי הנתבעת, עמוד 2, סעיף ב' לפסק הבוררות).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/420/2021
מס' בקשה: 6/552/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. בנספח 4 לסיכומי הנתבעת (להלן – "התמלול"), אילן אמר במהלך הדיון כי פנה אל מחלקת האכיפה בעיריית אלעד בטענה שהנתבעת ובעלה בנו על הגג המשותף (עמוד 10 שורות 14-18 לתמלול).

13. בדיון בהליך הבוררות אילן טען טענות בעלות במקרקעין.

14. אף הדיין בבוררות הגיע כדי לבחון את טענות התובע בקשר לזכויות בגג.

15. הליך הבוררות מחייב את התובע ואת אילן וזאת מאחר שהוכח שאין מחלוקת על כך שאילן ניהל בשם התובע את כל העניינים במקרקעין, לפיכך, חתימתו בשטר הבוררות מחייבת אותו ואת התובע להתדיין רק בבוררות, ובלשון שטר הבוררין "בכל התביעות והסכסוכים שביננו והמסתעף מהם".

טענות (המשיב) התובע בסיכומיו

16. הנתבעת קיבלה את הסכמת דיירי הבניין לבנייה בהיתר, אך לא קיבלה כל הסכמה לחריגה ולבניה ללא היתר על הרכוש המשותף.

17. הבוררות התנהלה בעניינים ממוניים בלבד, כבר בפתח הדיון נאמר כי מהות הדיון היא עצירת הבנייה המסוכנת בעקבות השלכת אבנים לחצר דירת המשיב, ובנושא הזה של דוד שמש.

18. בהתאם לסיכום הטענות בסופו של הדיון עולה כי הטענות שעמדו בפני בית הדין הרבני הם:

- א. נזקים שנגרמו לאילן (עמוד 36, שורה 11 לתמלול).
 - ב. שלא יפתח עסק בבניין (עמוד 36, שורה 16 לתמלול).
 - ג. העתקת הבויילרים למיקום גבוה יותר (עמוד 37, שורה 1).
- ולאחר סיכום הטענות תם הדיון.

19. למרבה הפליאה, בנימוקיו מציין הבורר נימוקים לעניין הפסיקה שלא הוזכרה כלל בפסק הביניים ואשר לא הייתה כל מחלוקת בעניין זה בהליך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/420/2021
מס' בקשה: 6/552/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הבוררות (עמוד 2, סעיף ב' לפסק הבוררות) ואף על פי שהטענה כלל לא הוזכרה בהליך הבוררות.

20. הבוררות לא דנה בעניינים קנייניים ושטר הבוררות הוא חוזה אחיד ללא כל אפשרות לשנות או לתקן אותו ולכן המשפט "כל התביעות והסכסוכים שביננו והמסתעף מהם" הוא תנייה מקפחת ברורה.

21. פסק הבוררות נוגד את תקנות הציבור, סעיף 24 (9) לחוק הבוררות קובע כי אפשר לבטל פסק בוררות במקרה שתכנו של הפסק מנוגד לתקנות הציבור.

22. בפסק הבוררות נקבע כי משהסכים אילן להצמדת השטח לדירתו של משה (בתור מרפסת/גג) הרי שהוא בהכרח הסכים גם לבניה בלתי חוקית באותו שטח, דבר אשר סותר את יסודות החוק שעליו מתבססים הדיירים בבית המשותף.

23. בהתאם לסעיף 5(ג) לחוק הבוררות, רשאי בית המשפט שלא לעכב הליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות. הבורר בפסק הדין מכשיר חריגות בנייה בהיקף נרחב וקובע כי אישור להצמיד לטובת שימוש במרפסת או בגג פתוחים מהווה אישור לבניית קומה נוספת.

דיון והכרעה

הסמכות העניינית

24. כפי שכתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/21 שפר מיכל נ' מירון נחום יצחק (נבו 26.01.2022) (להלן-"עניין שפר"), שאלת הסמכות העניינית היא שאלה מקדמית הדורשת תשובה ברורה וחדה, קיומה של אי-בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות הענייניות בין הערכאות הדיוניות השונות עלולה לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרום לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה (ראו לעניין זה: ע"א 9379/03 צ'רני נ' מדינת ישראל, פ"ד סא(3) 822, 833 (2006); ע"א 3347/16 פלונית נ' פלוני, [פורסם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/420/2021
מס' בקשה: 6/552/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בנבו[פסקה 9 (20.2.2018); שלמה לוי תורת הפרוצדורה האזרחית: מבוא ועקרונות יסוד 99 (מהדורה שנייה, 2008); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 52 (מהדורה שלוש עשרה, 2020)).

25. סעיף 1 לחוק הבוררות מגדיר הסכם בוררות כך:

"הסכם בוררות" – הסכם בכתב למסור לבוררות סכסוך שנתגלע בין צדדים להסכם או שעשוי להתגלע ביניהם בעתיד, בין שנקוב בהסכם שמו של בורר ובין אם לאו;

26. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין מעוגנת בהוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") המובאת כאן כלשונה:

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר (ההדגשה אינה במקור).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/420/2021
מס' בקשה: 6/552/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. כפי שהבהרתי לצדדים במסגרת הדיון, אין בכוונתי לסלק את התובענה, אך יש בכוונתי לבחון האם מתקיימים התנאים שבסעיף 5(א) לחוק הבוררות, כך שיש לעכב את ההליך ולהעבירו להליך הבוררות. וזו לשונו של סעיף 5(א) לחוק הבוררות:

"הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וביקש בעל-דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך."

28. סעיף 5 לחוק הבוררות מורה על שישה תנאים מצטברים בהתקיימם רשאי בית המשפט ובהתאמה מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, המפקח על רישום מקרקעין - **להורות על עיכוב הליכים** בתביעה שלפניו וזאת בשל הליכי בוררות, אלא אם יוכיח התובע כי קיים טעם מיוחד לכך שהסכסוך בין הצדדים לא יידון בבוררות. ששת התנאים בהתקיימם יש לעכב את הדיון, ולהעבירו להליך בוררות, הם:

- (1) קיים הסכם בוררות בין הצדדים, (2) התביעה שהוגשה לבית המשפט מתייחסת לסכסוך שההסכם חל עליו, (3) בעל דין שהוא צד להסכם מבקש את עיכוב ההליכים, (4) המבקש היה מוכן – ועודנו מוכן גם בעת הגשת הבקשה, לעשות את כל הדרוש לקיום הבוררות.
- (5) המבקש ביקש את עיכוב ההליכים בכתב ההגנה או בדרך אחרת.
- (6) המבקש פנה בבקשה לעיכוב הליכים לפני שטען לראשונה לגופה של התביעה. (ראו והשוו-ה"פ (מרכז) 43623-11-10 **שלום שרבט נ' מלכיאל שרבט**, ע"מ 11 (נבו) 14.08.2011).

29. כפי שצינתי בהחלטה בעניין שפר לעיל, בהתאם לגישה בפסיקה, גם כאשר מתקיימים כל התנאים לעיכוב ההליכים, נותר בידי הערכאה הדיונית שיקול דעת שלא להיעתר לבקשה "...אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות" (סעיף 5(ג) לחוק הבוררות). כאשר הנטל לשכנע כי יש להימנע מעיכוב הליכים בעניין שהוסכם לגביו כי יועבר לבוררות, מוטל על שכמי התובע שפנה לבית המשפט (רע"א 985/93 **אלרינה אינוסטמנט קורפוריישן נ' ברקי פטה המפריס (ישראל) בע"מ**, פ"ד מח(1) 397 (1993); רע"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/420/2021
מס' בקשה: 6/552/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7030/08 אחיסמך מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' עטורה
השקעות בע"מ (נבו 17.9.2008).

30. לפיכך, עיכוב הליכים לפי חוק הבוררות הוא עניין המצוי בשיקול דעתה של
הערכאה הדיונית (רע"א 4882/96 יעקב (ג'ק) נאסר נ' אדמונד ספרא (נבו
06.03.1997)).

31. אבחן להלן האם ששת התנאים כאמור מתקיימים בענייננו:

התנאי הראשון - קיום הסכם בוררות בין הצדדים

32. ככלל, הסכם בוררות מחייב רק את הצדדים החתומים עליו נוכח העובדה
שהליך הבוררות יונק חיותו מהסכמת הצדדים [רע"א 1950/20 זוהר יפה ואח'
נ' יהושע דיאמנט ואח', בפסקה 14 (נבו 10.5.2020)]. עיון בשטר הבוררין שצורף
לבקשה מעלה כי הצדדים החתומים עליו - מצד התובעים אוהד לוי ואילן
אליהו (בנו של התובע) - מצד הנתבע - משה כהן (בעלה של הנתבעת). משכך
על פניו נראה כי אין זהות ישירה בין הצדדים.

33. עם זאת, נפסק לא אחת כי יתאפשר צירופו להליך הבוררות, של גורם שאינו
חתום על הסכם הבוררות, כאשר הגורם שאותו מבוקש לצרף הוא צד קשור
ובעל עניין בהסכם הבוררות, זאת כדי למנוע מצדדים לחמוק מהשתתפות
בהליך בוררות לו הסכימו מהותית בטענות פורמליסטיות [רע"א 1030/15
גבריאל דדון נ' יהויכין יוסף חדד, בפסקה 9 (נבו 18.08.2015)].

34. לפיכך יש לבדוק האם הסכם הבוררות חל על התובע מכוח מעגלי ההרחבה.

35. בהתאם לפסיקה, קיימים מספר "מעגלי הרחבה" אשר מאפשרים לצרף
להליך הבוררות צד שאינו חתום על הסכם הבוררות. המעגל הראשון - כאשר
עולה מפרשנות הסכם הבוררות ומהמערכת החוזית ביניהם כי הסכימו
להיות חלק מהליך הבוררות. המעגל השני - מכוח סעיף 4 לחוק הבוררות
אשר מורה כי: "הסכם בוררות וסמכותו של בורר על פיו כוחם יפה גם לגבי
חליפיהם של הצדדים להסכם, וסמכותו של בורר על פי הסכם בוררות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/420/2021
מס' בקשה: 6/552/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מוקנית גם לבורר חליף, והכל כשאינן כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם.
(ההדגשה אינה במקור).

המעגל השלישי - מתייחס לאלו שקשורים בקשר הדוק לצדדים שחתמו על הסכם הבוררות אך עיקרון האישיות המשפטית יוצר הפרדה ביניהם. אחת המטרות של מעגל זה היא למנוע מצדדים לחמוק מהשתתפות בהליך בוררות שעליו הסכימו מבחינה מהותית בטענות פורמליסטיות [ראו והשוו - ת"א (כלכלית) 11675-01-19 דלק קידוחים - שותפות מוגבלת נ' המפקחים מחזיקי יחידות ההשתתפות בדלק קידוחים שותפות מוגבלת, פסקה 19 (נבו 24.06.2019); רע"א 3925/12 חן רונן נ' עו"ד יובל כהן, פסקה 14 (נבו 17.06.2013)].

36. אשר למעגל הראשון - נראה כי באופן משתמע הסכים התובע להיות חלק מהליך הבוררות. כעולה מפרוטוקול הדיון, התובע התחמק בחקירתו מלהשיב לשאלות בצורה עניינית וכשנשאל "אתה אומר שהבוררות לא הייתה מעניינדך?"

השיב התובע "לא מעניין אותי הבוררות אני באתי רק לגבי החריגה, איפה שלא הייתי אל תכניס אותי", וכנשאל שוב "אם אילן דיבר בבוררות על דברים של הגג וכל הדברים שקשורים לבעלות של הדירה זה מבחינתך לא על דעתך?"

ענה התובע "אני מדבר רק על החריגה". (ראו: עמוד 5, שורות 17-21 לפרוטוקול הדיון).

37. בנוסף לכך הוסיף אילן בהמשך:

"אני גר שם ומוצג כאילו אני הבעלים אני לא יביא את אבא שלי כי זה לא שייך להביא אותו, אמרתי כביכול אני הבעלים אבל לא בפועל". (ראו: עמוד 4, שורות 23-24 לפרוטוקול הדיון המקדמי). מדבריו של אילן ניתן להסיק כי לתובע בהליך הנוכחי היה ענין ממשי בנושא שנדון על ידי מר אילן בהליך הקודם. בנוסף לכך, ניתן להסיק כי התובע ידע על קיומו של ההליך הקודם ואף הייתה לו הזדמנות להצטרף אליו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/420/2021
מס' בקשה: 6/552/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

38. אשר למעגל השני - המושג "חליף" בסעיף 4 לחוק הבוררות לא הוגדר בחוק הבוררות, אלא פורש בפסיקה. בהתאם לגישה בפסיקה, בית המשפט רואה "כחליף" את מי שמשמש לאחד הצדדים להסכם הבוררות כ"ידו הארוכה של משנהו" וכשאפשר לראות כי יש "זהות אינטרסים" בין ה-"חליף" לבין הצד להסכם הבוררות. (ראו והשוו, ע"א 10892/02 נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' מרדכי זיסר, פסקה 16 (נבו 06.06.2005)).

39. בהתאם לכך, הקרבה הקיימת בין הצדדים בענייננו - התובע ואילן - אינה מתבטאת רק בקשר המשפחתי ביניהם, אלא בעיקר בשיתוף אינטרסים מלא ביניהם בנושא ההתדיינות בשני ההליכים. אין חולק על כך שאילן בן התובע, אינו בעל הזכויות בנכס אבל מתגורר בו, היה נציג התובע בהליכים שונים הקשורים לדירתו ושימש "כידו הארוכה", להלן הפירוט לכך:

א. אילן חתם על חוזה "מכתב הסכמה" בנושא הבניה בבית המשותף מתאריך ח' בתמוז תשע"ז (2.7.2017) (ראו נספח 3 לכתב ההגנה).

ב. אילן חתם על חוזה "כתב התחייבות" בנושא בניית מדרגות בבית המשותף מתאריך י"ט באלול תשע"ט (19.9.2019) (ראו נספח 4 לכתב ההגנה).

ג. ב"מכתב התראה לפני תביעה" מתאריך כ"ג בטבת תשפ"א (7.1.2021) נאמר כי התובעים הם אליהו ונחמה אליהו ואילו הליך הבוררות התנהל מול אילן (ראו נספח 5 לכתב ההגנה).

ד. בהמשך ישיר לכך, בהליך הבוררות אילן הציג את עצמו כבעל הנכס או כשלוחו של בעל הנכס, להלן דוגמאות לכך:

"אני רוצה את הגג שלי בחזרה, אני רוצה את הבניין בחזרה" (עמוד 14 שורה 13 לתמלול).

"אנחנו גם לא רוצים כלום, רוצים את מה שהיה לנו" (עמוד 14 שורה 19 לתמלול).

"כי זה הגג שלי רציתי למכור אותו" (עמוד 27 שורה 6 לתמלול).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/420/2021
מס' בקשה: 6/552/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"אני קניתי את הבניין הקטן" (עמוד 36 שורות 16-17 לתמלול).

ה. במהלך הדיון כשנשאל אילן "בעצם ההלוואה ניתנה לך לא לאבא שלך?" השיב: "אני הייתי הייפוי כוח שלו, זה בהסכמתו" (ראו: עמוד 4, שורות 4-5 לפרוטוקול הדיון המקדמי). וכשנשאל אילן: "בבניה וויתרתם אתה ואבא שלך בזכויות על הגג המשותף?" השיב: "איפה שיש התר חתמנו והסכמנו לו". (ראו: עמוד 4, שורות 8-9 לפרוטוקול הדיון המקדמי).

40. לפיכך, קיימים יחסי קרבה משפטית וזהות אינטרסים בין התובע בהליך שלפניי, לבין אילן, התובע בהליך הבוררות. בית המשפט העליון התייחס לעניין זהות הצדדים בפסק דין ע"א 8444/19 ישעיהו גיבור נ' אזורים בנין (1965) בע"מ (נבו 26.04.2022), (להלן – "עניין ישעיהו"): "בדרך כלל, זהות הצדדים בשני ההליכים היא תנאי לקיומו של השתק העילה, וזאת מכוח עקרון ההדדיות. ואולם, גם בעל דין שלא היה צד להליך הראשון יהיה מנוע מלשוב ולהתדיין בנושא או בשאלה שהוכרעה בפסק דין חלוט שניתן על ידי בית משפט מוסמך מקום בו מתקיימים בינו לבין מי מבעלי הדין בהתדיינות הראשונה יחסי "קרבה משפטית" (ההדגשה אינה במקור).

41. "קרבה משפטית" כאמור עשויה להיווצר, בשל קשרים משפחתיים, מסחריים, מכוח נציגות או מכוח זיקה משותפת לעניין כספי משותף. המבחן לכך נעוץ בשאלה האם מצויים שיקולים של מדיניות משפטית המצדיקים השוואת מעמדו של בעל דין בהליך נוכחי למעמדו של בעל דין בהליך הקודם, הזדהות באינטרסים וקשירתם לתוצאותיו. בנוסף לכך יש לבחון את השאלות הבאות:

- א. האם בעל דין בהליך הנוכחי היה ענין ממשי בנושא שנדון על ידי בעל הדין בהליך הקודם.
- ב. האם בעל הדין בהליך הנוכחי ידע על קיומו של ההליך הקודם.
- ג. האם לבעל הדין בהליך הנוכחי הייתה הזדמנות להצטרף אל ההליך הקודם אך הוא נמנע מכך באופן מודע. (ראו והשוו: (המפקח על המקרקעין פתח



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/420/2021
מס' בקשה: 6/552/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תקוה) 66/07 **נירית הניה סגל נ' שלום יונה רוב** (נבו 24.02.2011); רע"א
7831/99 **אהרון צוריאנו נ' ד"ר אברהם צוריאנו**, נז(1) 673 689-690 (2002);
רע"א 7401/00 **יחזקאלי נ' עו"ד גלוסקה, כונס נכסים בעמ' 303-304**
(25.11.02).

42. לפיכך קיימת "קרבה משפטית" מובהקת בין אילן, התובע בהליך הבוררות לבין מנשה אליהו, אביו של אילן אשר משמש תובע בהליך שלפניי. כמו כן קיימת "קרבה משפטית" בין משה כהן, הנתבע בהליך הבוררות לבין אפרת רחל כהן, אשתו של משה והנתבעת שבהליך שלפניי.

43. אשר **למעגל השלישי** - בהתאם לגישה בפסיקה, "מעגל זה הוא מרחיק לכת מבחינת עקרון היסוד של הסכמת הצדדים לבוררות, ולכן, יש לנהוג בזהירות בבואנו להכניס לגדרו צדדים שלא נכללו במעגל ההרחבה הראשון כדי שלא נסתור את עיקרון ההסכמה המצוי ביסודו של הליך הבוררות (רע"א 2639/14 **ברימר נ' עטר**, [פורסם בנבו] פסקה 18 (9.12.2015)).

בהתאם לכך, ניתן יהיה לצרף להליך צד בהיעדר הסכמה רק במצבים יוצאי דופן שבהם צדדים מבקשים "לחמוק מהשתתפות בהליך בוררות לו הסכימו מבחינה מהותית בטענות פורמליסטיות, דוגמת הסתמכות על עקרון האישיות המשפטית הנפרדת" (ראו והשוו רע"א 5184/17 **בראשית יהלומים בע"מ נ' בנימין נמדר**, פסקה 7 (נבו 17.09.2017)).

44. בהתאם לכך, לא נעלמה מעיניי אמירותיו של אילן בהליך הבוררות (ראו: עמוד 29 שורות 10-14 לתמלול).

-אילן: "כן שאנחנו נלך לבית משפט אני אשלם לך".
-משה: "אתה לא יכול ללכת לבית משפט".
-אילן: "אז בסדר. אז לא אני אז אשתי תלך".
-משה: "אתה חתום".
-אילן: "אז אשתי תלך".

45. מכאן, שבהתאם לאמור בניתוח המעגל הראשון לעיל, ניתן להצביע על הסכמה מהותית של התובע להשתתף בהליך הבוררות. ובהתייחס לדבריו של אילן בהליך הבוררות כאמור, אין ספק כי התובע מנסה לחמוק מהשתתפות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/420/2021
מס' בקשה: 6/552/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהליך בוררות לו הסכים מבחינה מהותית על ידי שימוש בטענות
פורמליסטיות.
לפיכך התנאי הראשון שביסוד סעיף 5 לחוק הבוררות, מתקיים.

התנאי השני - התביעה שהוגשה לבית המשפט מתייחסת לסכסוך שההסכם חל
עליו

46. בתביעה שלפניי מדובר באותו נכס נושא המחלוקת ובאותן הנסיבות
העובדתיות שנדונו בהליך הבוררות. בנוסף לכך, בהתייחס ללשון שטר
הבוררין עליו חתמו אילן ומנשה כהן, הועברו לדיינים כל התביעות
והסכסוכים שבין הצדדים והמסתעף מהם (ראו נספח 6 לכתב ההגנה). כמו
כן יודגש כי בשטר הבוררין עליו חתמו אילן ומנשה נרשם כי לא תהיה לצדדים
זכות ערעור לפני בית משפט אחר או ערכאה כלשהי.

47. בניגוד לטענות התובע בסיכומיו, התביעה בהליך הבוררות לא עסקה
בעניינים ממוניים בלבד, אלא הועלו ונדונו מחלוקות קנייניות מצדו של אילן,
לדוגמה:

א. במהלך הדיון בהליך הבוררות טען אילן: "ביקשתי בבקשה שיבנה, הוא
רוצה לבנות בחריגות שיבנה, את הבוילרים שלא יזיז ממקומם".
-דיין: "אוקי הבנו אוקי".
(ראו עמוד 13 שורות 9-11 לתמלול).

ב. "משה: על מה אני חורג, אני בונה מעל הבית שלי לא חור... כבוד הרב
היה אצלי, הרב ראה, אני חורג?
-אילן: טוב. אולי (לא ברור).
-משה: אני חורג בסנטימטר? אני בונה מעל הבית שלי.
-אילן: בסדר יכול להיות שאני טועה בגלל זה באנו לדיון".
(ראו עמוד 29, שורות 3-6 לתמלול).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/420/2021
מס' בקשה: 6/552/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

48. בנוסף לכך, מפסק הבוררות עולה כי בהליך הבוררות הייתה התייחסות לטענות הקנייניות שהועלו מטעם התובע במהלך המשפט. כבר בתחילת פסק הבוררות נאמר כי:

"הטענה הראשונה הייתה על שנגרם נזק מחמת הבניה של הקומה ב' ומעל הגג מחמת הבניה.

טענה שניה הייתה היות והנתבע גר בקומה אחרונה בנוסף לתוס' הוא הרחיב את כל קומת הגג בכל תווי הדירה שלו על הגג עם התוס' החדשה והעלה את דודים מעל התוס' ומעל השטח שהיה מעל דירתו בגג ריצף ועשה מחסן ופרגולה וריצף הגג כולו. (ראו: נספח 3 לסיכומי הנתבעת, עמוד 2, שורות 5-8 לפסק הדין), (ההדגשות אינן במקור).

49. גם בסופו של פסק הבוררות הייתה התייחסות לכך:

"לגבי הטענה על הרחבה גדולה יותר מהתוספת בזה שבנה על כל הגג מאחר וחתמו כל הדיירים שבאפשרותו לרצף הגג ברור ומוסכם שהסכימו לצרף להצמיד את השטח הנ"ל לדירה או לתוס' א"כ ברור שיש בידו להרחיב ולבנות על שטח החצר הזה שהוצמד לדירתו ע"פ חתימת כל השכנים" (ראו: נספח 3 לסיכומי הנתבעת, עמוד 2, סעיף ב' לפסק הדין), (ההדגשה אינה במקור).

50. לפיכך, ובניגוד לטענת התובע, בהליך הבוררות נדונו לא רק נושאים ממוניים, אלא גם נושאים קנייניים הבהירים לטענות שהועלו בפניי בכתב התביעה, לפיכך מתקיים גם התנאי השני המופיע בסעיף 5 לחוק הבוררות.

גם התנאים השלישי הרביעי החמישי והשישי מתקיימים

51. בתאריך י"ב בחשוון תשפ"ב (18.10.2021) ביקשה הנתבעת, בהזדמנות הראשונה ועוד לפני שטענה לגוף התביעה, לסלק את התביעה על הסף מכיוון שלטענתה בעניין זה נחתם שטר בוררות. לדבריה, קיים הליך תלוי ועומד בנושא ואף ניתן לצדדים פסק דין ביניים. לפיכך, וכמשתמע מטענות הנתבעת היא מוכנה לקיים את הבוררות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/420/2021
מס' בקשה: 6/552/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

52. מתקיימים כל תנאיו של סעיף 5(א) לחוק הבוררות. לפיכך, ההליך שבכותרת יעוכב. בתוך 14 ימים מהיום, תפנה הנתבעת לבית הדין הרבני (בית דין צדק חושן משפט) שבו מתקיים הליך הבוררות, ותגיש לתיק העתק מפנייתה לתיק. הצדדים יגישו הודעת עדכון בדבר הליך הבוררות עד לתאריך ו' בחשון תשפ"ג (31.10.2022), או עם סיום הליך הבוררות, לפי המוקדם.

הוצאות הבקשה

53. אשר להוצאות הבקשה - תקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 מחייבת כברירת מחדל, פסיקת הוצאות הבקשה, וזאת ללא כל קשר לתוצאות ההליך העיקרי.

54. לפיכך, אני מורה לתובע לשלם לנתבעת, את הוצאות הבקשה, בסך כולל של 5,000 ₪, שישולמו בתוך שלושים ימים מהיום, ככל שלא ישולמו במועד, יישאו בהפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן ההחלטה, ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, 25 ביולי 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה